

1015121-65.2021.8.26.0309
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Base de Cálculo
Magistrado: Gustavo Pisarewski Moisés
Comarca: Jundiaí / SP
Foro: Foro de Jundiaí
Vara: Vara da Fazenda Pública
Data de Disponibilização: 06/05/2022

... de que "o ICMS não é imposto incidente sobre tráfico jurídico, não sendo cobrado, por não haver incidência, pelo fato de celebração de contratos", razão pela qual, no que se refere à contratação de demanda de potência elétrica, "a só formalização desse tipo de contrato de compra ou fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza circulação de mercadoria". Afirma-se, assim, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jundiaí / SP
Foro de Jundiaí
Vara da Fazenda Pública
Senador Fonseca 957, Jundiaí - SP - cep 13201-017
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1015121-65.2021.8.26.0309 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1015121-65.2021.8.26.0309
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Base de Cálculo
Requerente:
Eban Empreendimentos Imobiliários Ltda
Requerido:
Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo Pisarewski Moisés

Vistos.

Trata-se de ação ajuizada por EBAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – FESP, inicial a fls. 01/20, documentos a fls. 21/55.

Pretende a parte autora, em suma: i) a concessão de medida liminar, 'para determinar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário referente à exclusão da demanda contratada da base de cálculo do ICMS devido nas operações com energia elétrica (consumo) referente à unidade consumidora nº 4000491457'; e ii) ao final, a procedência da ação, 'para que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e a fazenda pública do Estado, reconhecendo o direito à exclusão da demanda contratada da base de cálculo do ICMS devido nas operações com energia elétrica, bem como seja ao final determinado à concessionária distribuidora a exclusão dos respectivos valores das faturas de energia elétrica futuras, tudo a partir da data da propositura da ação, referente a unidade consumidora nº 4000491457', além da 'restituição ou compensação (conforme critério do autor) dos valores indevidamente recolhidos correspondentes à inclusão da demanda contratada na base de cálculo do ICMS devido nas operações com energia elétrica dos últimos 05 anos anteriores à propositura da ação, bem como dos valores recolhidos durante o

trâmite da ação, acrescidos da taxa SELIC a contar da data do recolhimento indevido, referente à unidade consumidora de N°4000491457'.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida "para, com fundamento no artigo 151, V, CTN, decretar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ICMS incidente sobre a operação de fornecimento de energia elétrica contratada e não utilizada, incidindo ICMS apenas sobre a operação de fornecimento de energia elétrica efetivamente consumida em seu estabelecimento", fls. 56/64.

O réu apresentou contestação, batendo-se pela improcedência da ação, fls. 93/128.

Embargos de declaração da parte autora a fls. 138/140, rejeitados a fls. 141.

Da decisão que deferiu em parte a tutela de urgência foi tirado recurso de agravo pela parte autora, ao qual foi negado provimento, fls. 157/164.

A parte autora não se manifestou em réplica, apesar de intimada, fls. 165.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

De rigor o julgamento do feito no estado em que se encontra.

Presentes estão as condições da ação e os pressupostos processuais, sem nulidade a ser sanada.

Em especial, apesar da parte autora não ser o contribuinte de direito, mas sim o de fato, tem ela legitimidade para discutir em juízo a exação em questão, confira-se:

"RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A DEMANDA 'CONTRATADA E NÃO UTILIZADA'. LEGITIMIDADE DO CONSUMIDOR PARA PROPOR AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. - Diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público e da peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o consumidor, esse último tem legitimidade para propor ação declaratória c/c repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada. - O acórdão proferido no REsp 903.394/AL (repetitivo), da Primeira Seção, Ministro Luiz Fux, DJe de 26.4.2010, dizendo respeito a distribuidores de bebidas, não se aplica ao casos de fornecimento de energia elétrica. Recurso especial improvido. Acórdão proferido sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil" - Recurso Especial n. 1299303/SC, 1ª Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministro Cesar Asfor Rocha, j. 08.08.2012.

"PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL - ICMS - ENERGIA ELÉTRICA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - LEGITIMIDADE DO CONTRIBUINTE DE FATO - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. No tocante à legitimidade ativa, de acordo com a atual orientação desta Corte, fixada no julgamento do REsp 903.394/AL, sob o regime dos recursos repetitivos, somente o contribuinte de direito tem legitimidade ativa para a demanda relacionada aos tributos indiretos, ou seja, aqueles em que o ônus tributário, pela própria natureza e sistemática da exação, repercute-se no patrimônio do contribuinte de fato, nos termos do art. 166 do CTN (REsp 928875/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 01/07/2010). 2. No entanto, em relação à legitimidade ativa especificamente do consumidor de energia elétrica, a Primeira Seção desta Corte, em recurso julgado também sob a sistemática do art. 543-C do CPC, pacificou o entendimento de que, diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público e da peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o consumidor, esse último tem legitimidade processual para questionar a incidência do

ICMS sobre a energia elétrica, com fundamento no art. 7º, II, da Lei 8.987/95, não obstante as disposições do art. 166 do CTN, que veiculam regra geral de legitimidade apenas ao contribuinte de direito. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de se reconhecer a legitimidade do embargante para pleitear repetição/compensação de indébito" - Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1270547/RS, 2ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministra Eliana Calmon, j. 04.06.2013.

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO. I - O acórdão embargado não apreciou as questões apresentadas no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, porquanto concluiu pela ilegitimidade ativa da Impetrante, sob o fundamento de que os consumidores de energia elétrica não possuem legitimidade ativa para pleitear a repetição de eventual indébito tributário do ICMS incidente sobre essas operações. II - O consumidor possui legitimidade para propor ação declaratória cumulada com repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada. III - Embargos de Declaração acolhidos com excepcionais efeitos infringentes, a fim de anular o acórdão embargado e determinar o retorno dos autos para nova análise do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança" - Embargos de Declaração no Recurso em Mandado de Segurança n. 33.838/CE, 1ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministra Regina Helena Costa, j. 15.12.2015.

"Apelação Cível/Remessa necessária, Tributário, Mandado de Segurança - Pretensão de exclusão da TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS. Segurança concedida. Remessa necessária e recurso da FESP. Desprovidos de rigor. 1. Ilegitimidade ativa 'ad causam' não configurada. Autora que suportou diretamente o encargo tributário, sendo consumidora final de energia elétrica Precedentes. 2. No Mérito, a TUSD e a TUST não integram a base de cálculo do ICMS, conforme reiteradamente decidido pelo C. STJ. Sentença mantida - Preliminar rejeitada, Remessa Necessária e Recurso da FESP desprovidos" - Apelação / Reexame Necessário nº 1023194-36.2015.8.26.0309, 6ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Sidney Romano dos Reis, j. 22.08.2016.

E ao fim, não há se falar em falta de interesse de agir.

A uma, porque a via processual adotada pelo autor se apresenta adequada para o alcance da pretensão deduzida na inicial.

A duas, porque a resistência concreta ofertada em contestação pelo réu dá conta da existência da lide e da necessidade do ajuizamento da demanda.

Outrossim, o prévio pedido administrativo não é condição necessária ao socorro imediato à via judicial e não descaracteriza a lide em casos que tais, porquanto é notória a resistência externada pela fazenda pública à pretensão ora deduzida em juízo pela parte autora, como, aliás, bem se denota na peça de contestação.

A respeito:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se

confunde com o esgotamento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. (...)” – Recurso Extraordinário, Pleno do Col. Supremo Tribunal Federal, m. v., relator Ministro Roberto Barroso, j. 03.09.2014.

Nesse passo, não se justifica a extinção anômala do processo, para compelir a parte autora ao socorro ao prévio contencioso administrativo, que, após, diante da resistência do réu aqui já externada, terá que ajuizar nova ação.

Se a pretensão vem a ser deduzida em juízo e se o réu oferece resistência concreta em seu mérito, buscando a rejeição do pedido, com fins de alcançar a força de coisa julgada ao final, não tem cabimento algum não ser examinada e definitivamente decidida aqui a questão de fundo ora posta e ora litigiosa.

No mesmo sentido:

"Apelação e Remessa Necessária. Ação declaratória c/c repetição de indébito. Servidor público inativo e portador de doença incapacitante (cardiopatia grave). Afastada preliminar de falta de interesse de agir. Ausência de negativa administrativa. Observância do direito constitucional de acesso à justiça. Exigência de prévio requerimento administrativo que não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for reiteradamente contrário à postulação. Mérito. Isenção de imposto de renda previsto no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Contemporaneidade dos sintomas desnecessária. Existência da enfermidade que é incontroversa. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Benefício fiscal de redução de contribuição previdenciária indevido. Ausência de lei regulamentadora. Entendimento firmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral 317. Lei Complementar Estadual nº 1354/2020 que revogou o benefício. Sentença reformada em parte. Remessa necessária e recurso voluntário parcialmente providos" – Apelação n. 1024011-18.2020.8.26.0506, 3ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargadora Paola Lorena, j. 09.03.2022.

"Apelação. Ação de Repetição de Indébito. Questionamento acerca da competência para a exigência do ISS. Serviços de Construção civil. Município de Salto de Pirapora. Sentença que julgou procedente o pedido, sob o fundamento de que o fato gerador ocorreu nos limites do Município de Sorocaba, local da obra. Pretensão à reforma manifestada pelo ente municipal tão somente quanto ao não reconhecimento da ausência de interesse de agir. Desacolhimento. Propositura de ação judicial que não depende de esgotamento prévio da via administrativa (art. 5º, XXXV, CF), consoante o posicionamento das duas Turmas que compõem a Primeira Seção especializada em direito público do C. STJ. Inteligência do acórdão proferido no RE 631.240. Sentença mantida. Recurso ao qual se nega provimento". – Apelação n. 1000456-72.2020.8.26.0699, 18ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Ricardo Chimentí, j. 16.12.2021.

"MANDADO DE SEGURANÇA – Apelação – Município de São Paulo – ISS – Sociedade de médico que adota a forma EIRELI – Pedido de recolhimento do ISSQN pelo regime de alíquota fixa, nos termos do Decreto-lei nº 406/68, art.9º, §§ 1º e 3º - Sentença que não concedeu a segurança, pela ausência do critério subjetivo da extensão da responsabilidade ao empresário - Afastamento das preliminares de inadequação da via eleita e ausência de interesse de agir - Impetrante não está obrigada a esgotar a esfera administrativa, podendo desde logo, pretender a via jurisdicional - Elementos dos autos que demonstram que a negativa se deu exclusivamente pelo fato da impetrante ter características empresarial e responsabilidade limitada, sem contudo haver análise do ato constitutivo, o que inviável nos termos da jurisprudência mais recente do c.STJ - Atividade médica que, a princípio, tem caráter personalíssimo e responsabilidade pessoal do profissional pelo serviço de saúde, fazendo jus ao regime especial, sendo a responsabilidade limitada restrita

às obrigações assumidas pela sociedade, e não ao serviço prestado pessoalmente pela sócia - Município que, ao não demonstrar a característica empresarial, torna ilegal a negativa de recolhimento do tributo pelo regime especial - Incabível a repetição de valores em sede de mandado de segurança já que não admite a produção de provas, devendo a apelante eventualmente ingressar com a respectiva ação de repetição de indébito, onde poderá exercer ampla dilação probatória, apresentando documentos dos valores recolhidos a maior - Prejudicada a análise da antecipação da tutela recursal - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido" - Apelação n. 1073921-78.2021.8.26.0053, 15ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargadora Tania Mara Ahualli, j. 04.04.2022.

O mais toca ao mérito da lide e com ele se confunde.

No mérito, a ação é parcialmente procedente.

Vejamos, na esteira do que já constou da decisão que deferiu a medida de urgência.

Deveras, é firme o entendimento jurisprudencial, já pacífico, de que não há lastro jurídico na incidência de ICMS sobre energia elétrica contratada e não utilizada, pois ausente a ocorrência do fato gerador do imposto, que é a efetiva (e não ficta) circulação econômica de mercadoria.

A questão já foi inclusive resolvida em sede de precedentes vinculantes, artigo 927, NCPC, confira-se:

"É indevida a incidência de ICMS sobre a parcela correspondente à demanda de potência elétrica contratada mas não utilizada" - Tema de Recurso Repetitivo n. 63 do E. Superior Tribunal de Justiça, afetado ao Recurso Especial n. 960476/SC, 1ª Seção, m. v., relator Ministro Teori Zavaski, j. 11.03.2009.

"A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor" - Tema de Repercussão Geral n. 176 do Col. Supremo Tribunal Federal, afetado ao Recurso Extraordinário n. 593824/SC, Pleno, m. v., relator Ministro Edson Fachin, j. 19.05.2020.

Nesse mesmo sentido:

"O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada" (Súmula n. 391 do E. Superior Tribunal de Justiça).

"TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA CALCULADA COM BASE EM DEMANDA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA. INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA CALCULADA COM BASE NA DEMANDA DE POTÊNCIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE UTILIZADA. 1. A jurisprudência assentada pelo STJ, a partir do julgamento do REsp 222.810/MG (1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 15.05.2000), é no sentido de que "o ICMS não é imposto incidente sobre tráfico jurídico, não sendo cobrado, por não haver incidência, pelo fato de celebração de contratos", razão pela qual, no que se refere à contratação de demanda de potência elétrica, "a só formalização desse tipo de contrato de compra ou fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza circulação de mercadoria". Afirma-se, assim, que "o ICMS deve incidir sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida, isto é, a que for entregue ao consumidor, a que tenha saído da linha de transmissão e entrado no estabelecimento da empresa". 2. Na linha dessa jurisprudência, é certo que "não há hipótese de incidência do ICMS sobre o valor do contrato referente à garantia de demanda reservada de potência". Todavia, nessa mesma linha jurisprudencial, também é certo

afirmar, a contrario sensu, que há hipótese de incidência de ICMS sobre a demanda de potência elétrica efetivamente utilizada pelo consumidor. 3. Assim, para efeito de base de cálculo de ICMS (tributo cujo fato gerador supõe o efetivo consumo de energia), o valor da tarifa a ser levado em conta é o correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada no período de faturamento, como tal considerada a demanda medida, segundo os métodos de medição a que se refere o art. 2º, XII, da Resolução ANEEL 456/2000, independentemente de ser ela menor, igual ou maior que a demanda contratada. 4. No caso, o pedido deve ser acolhido em parte, para reconhecer indevida a incidência do ICMS sobre o valor correspondente à demanda de potência elétrica contratada mas não utilizada. 5. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08" – Recurso Especial n. 960.476/SC, 1ª Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministro Teori Albino Zavascki, j. 13.05.2009.

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA MAS NÃO UTILIZADA. NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 960.476/SC, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é indevida a incidência do ICMS sobre o valor correspondente à demanda de potência elétrica contratada mas não utilizada. IV - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Agravo Interno improvido" – Agravo Interno no Recurso Especial n. 1430460/GO, 1ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministra Regina Helena Costa, j. 23.08.2016.

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC/73, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. 2. A Corte Estadual não se manifestou sobre as alegações de impossibilidade do pedido de compensação, inadequação da via eleita e prescrição das parcelas anteriores a abril de 2004, tampouco essas questões foram objeto dos embargos declaratórios opostos. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 3. A Primeira Seção deste STJ, ao julgar o REsp 960.476/SC, consolidou a compreensão de que "É indevida a incidência de ICMS sobre a parcela correspondente à demanda de potência elétrica contratada mas não utilizada" (Tema 63 dos Recursos Repetitivos). 4. Agravo regimental a que se nega provimento" – Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1325024/GO, 1ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministro Sérgio Kukina, j. 09.08.2016.

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL, PELO STF. ART. 543-B DO CPC. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FATO GERADOR DO ICMS RELATIVO À ENERGIA ELÉTRICA.

ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA E NÃO A MERA DEMANDA CONTRATADA OU RESERVADA DE POTÊNCIA. SÚMULA 391 DO STJ E RESP 960.476/SC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Na linha da jurisprudência desta Corte, o fato de a matéria estar pendente de julgamento, no Supremo Tribunal Federal, com reconhecimento de repercussão geral, não obsta o julgamento, nesta Corte, do Recurso Especial. O exame de eventual necessidade de sobrestamento do feito terá lugar quando do juízo de admissibilidade de eventual Recurso Extraordinário a ser interposto, a teor do art. 543-B do Código de Processo Civil. Nesse sentido: STJ, AgRg no RESP 1.411.517/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/03/2014; AgRg no AgRg no AREsp 367.302/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/02/2014. II. Estabelece a Súmula 391/STJ que "o ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada". III. Na esteira da diretriz firmada na Súmula 391/STJ, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o RESP 960.476/SC, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que o fato gerador do ICMS, no caso de fornecimento de energia elétrica, é a energia efetivamente consumida. Entendeu-se, assim, que deveria ser excluída, da base de cálculo do ICMS, a demanda de potência contratada ou reservada e não utilizada. IV. Não há de se cogitar de jurisprudência oscilante, quando os supostos precedentes, em sentido contrário, ou não se aplicam ao caso dos autos, ou se encontram já superados pelo entendimento atual desta Corte. V. Agravo Regimental improvido" - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 554.115/CE, 2ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministra Assusete Magalhães, j. 27.10.2015.

Segue-se daí que não integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica 'eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada'.

Acrescenta-se, a afastar qualquer confusão ou tergiversação, que, se a demanda de energia elétrica é contratada e não utilizada, sobre ela não incide ICMS, por falta de fato gerador, mas, contratada a demanda e uma vez utilizada, sobre a respectiva extensão incide ICMS, pois aí sim há fato gerador, esse o teor do entendimento firmado no Tema de Recurso Repetitivo n. 63 do E. Superior Tribunal de Justiça e no Tema de Repercussão Geral n. 176 do Col. Supremo Tribunal Federal.

Logo, não há qualquer fundamento, com todo o respeito a entendimento diverso, a pretensão de não incidir ICMS sobre a 'totalidade da demanda contratada'.

Via de consequência, quanto ao pagamento feito de ICMS sobre demanda não utilizada ou consumida, a parte autora faz jus à respectiva repetição de indébito, vez que configurada a hipótese do artigo 165, CTN.

Por certo, "(...) Segundo preconiza o art. 165 do CTN, o recolhimento indevido de tributo implica obrigação do Fisco de devolução do indébito ao contribuinte detentor do direito subjetivo de exigi-lo" - Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 974.997/SP, 2ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministro Francisco Falcão, j. 08.02.2018.

Irrelevante a circunstância de ter havido pagamento voluntário, pois isso não afasta o direito ao indébito, vez que é dispensável a prova do erro do contribuinte, na exata dicção do artigo 165, CTN.

É que o artigo 165 do CTN diz que "o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo" nos casos de pagamento indevido.

E, o fato de o artigo 165 do CTN expressamente "(...) ressaltar o protesto significa que ele é uma faculdade posta ao contribuinte, e mais, que a fazenda pública não pode exigir o protesto como condição da repetição. Em resgate

histórico, observo que a inserção do dispositivo no CTN, inclusive, foi feita em razão de existir anteriormente a sua vigência interpretação fazendária no sentido de que o protesto judicial do contribuinte (na época feito na forma do art. 720, do CPC/39 - Decreto-Lei n. 1.608/39) era obrigatório para ressaltar seus direitos quando do pagamento que entendeu indevido (cf. Aliomar Baleeiro in "Direito Tributário Brasileiro", 11ª ed. Rio de Janeiro, Forense: 2000, p. 877). (...) - Recurso Especial n. 1329901/RS, 2ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator ministro Mauro Campbell Marques, j. 23.04.2013.

Vê-se, pois, que o CTN expressamente dispensa a prova do erro do contribuinte como condição do indébito, até porque, tratando-se de tributo, que tem caráter de obrigação, ainda que possa ser indevido (a ser, então, objeto de discussão judicial), pagamento voluntário e espontâneo efetivamente nunca há.

A respeito, confira-se a doutrina:

"1. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. Velho e universal princípio do Direito, atribuído a Pomponio, não tolera locupletamento indevido com alheia jactura. Várias disposições legais mandam restituir o recebido indevidamente, ainda que, seguindo diretriz doutrinária de Beviláqua, o princípio não esteja enunciado com essa generalidade no Código Civil, que preferiu regular separadamente sua aplicação em cada instituto. No Direito Fiscal Brasileiro, em certo tempo, houve controvérsia acerca da aplicação daquela regra multissecular e de base ética, porque o Erário invocava a necessidade de o contribuinte provar que pagara por erro. É que o CC, embora estatuinte, no art. 964, que 'todo aquele que recebe o que lhe não era devido fica obrigado a restituir', dispõe no art. 965: 'ao que voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro'. Naturalmente, para proteger a boa-fé do que recebeu por doação, ou teve vantagem adicional para conceder condições, prazo etc., num negócio. Mas a melhor doutrina e a jurisprudência reagiram demonstrando que, pela natureza compulsória dos tributos, o solvens, quem os paga, não teve escolha, a menos que se sujeitasse aos vários vexames decorrentes dos privilégios do accipiens, no caso, o Fisco. Carvalho Santos, comentando o art. 964 (C. Civ. Br. Interp., 1945, XII, p. 396), diz que, 'em se tratando de pagamento de impostos indevidos, essa regra tem inteira aplicação, mesmo que o contribuinte pague sem resistência judicial'. (...) O art. 165 cortou a discussão, assegurando a repetição 'independente do prévio protesto', sem exigir a prova do erro" - Direito Tributário Brasileiro, Aliomar Baleeiro, ed. Forense, 11ª edição, p. 877/878.

Nesse mesmo sentido:

"(...) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Obras de pavimentação Municipalidade de Itapira - Exigência do tributo mediante rateio do custo da obra - Inadmissibilidade - Exigência prevista no DL 195/67, não revogado - Observância da valorização do imóvel não abolida pela atual Constituição Federal - Precedentes jurisprudenciais - Critério não observado - Hipótese, ademais, em que o lançamento tributário ocorreu com base em serviço de manutenção e conservação de via - Nulidade do lançamento - Cabimento da repetição dos valores pagos indevidamente - Pagamento espontâneo dos tributos que não pode constituir obstáculo à apreciação, pelo Judiciário, da legalidade da exação, bem como não veda a pretensão à repetição de indébito - Exegese do artigo 165 do Código Tributário Nacional - Elevação da verba honorária em favor do autor, de acordo com os critérios estabelecidos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do artigo 20 do CPC - Ação procedente - Sentença reformada parcialmente, apenas quanto a questão dos honorários advocatícios - Recursos oficial e voluntário da Municipalidade desprovidos, e provido, em parte, o recurso adesivo do autor. (...). Conforme lição de Hugo de Brito Machado: 'De acordo com o art. 165 do CTN, o sujeito passivo tem direito à restituição do tributo que houver pago indevidamente, Esse direito independe de prévio protesto, não sendo, portanto, necessário que ao pagar o sujeito passivo tenha declarado que o fazia 'sob

protesto'. O tributo decorre da lei e não da vontade, sendo por isso irrelevante o fato de haver sido pago voluntariamente. Na verdade o pagamento do tributo só é voluntário no sentido da inocorrência de atos objetivando compelir alguém a fazê-lo. Mas é óbvio que o devedor do tributo não tem alternativas. Está obrigado por lei a fazer o pagamento. Estes esclarecimentos são interessantes porque no Direito Civil há regra expressa dizendo que quem paga voluntariamente só terá direito à restituição se provar que o fez por erro (Código Civil [1916], art. 965). Aliás, essa regra chegou a ser invocada pelo Fisco para não restituir tributos, mas a tese foi repelida pelos tribunais e hoje, diante do CTN, dúvida não pode mais haver quanto ao direito à restituição' (Direito Tributário Brasileiro, 10a edição, Rio de Janeiro, Forense, 1996, p. 137). E, ainda: '... As quantias exigidas pelo Estado, no exercício de sua função impositiva, ou espontaneamente pagas pelo administrado, na convicção de solver um débito fiscal, têm a fisionomia própria das entidades tributárias, encaixando-se bem na definição do art. 3º do Código Tributário Nacional. A contingência de virem a ser devolvidas pelo Poder Público não as descaracteriza como tributo e para isso é que existem os sucessivos controles de legalidade que a Administração exerce e dos quais também participa o sujeito passivo, tomando a iniciativa ao supor descabido o que lhe foi cobrado, ou postulando a devolução daquilo que pagara indebitamente. Não sendo suficiente o procedimento administrativo que para esse fim se instale, terá o interessado acesso ao Poder Judiciário, onde poderá deduzir, como os recursos inerentes ao processo judicial, todos os argumentos e provas que dêem substância aos seus direitos' (Código Tributário Nacional comentado, RT, Manoel Álvares, p. 714, comentários ao artigo 165). Portanto, o pagamento indevido faz surgir o direito à repetição, sendo descabido o obstáculo imposto, de forma que de rigor manter a sentença também nesse aspecto. (...) - Apelação nº 9199929-46.2009.8.26.0000 (n. 994.09.294824-8), 14ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Gonçalves Rostey, j. 11.03.2010, grifo nosso.

A restituição deve se dar de forma simples (e não em dobro, pois ausente amparo legal para tanto), sendo que o valor do indébito deve ser apurado em liquidação por cálculo ou arbitramento, conforme o caso, incidindo sobre essa monta os encargos legais da mora e sempre observando a prescrição quinquenal (artigo 168, CTN, combinado com a Súmula n. 85 do E. Superior Tribunal de Justiça).

E em relação aos encargos da mora, de se observar o que segue, tratando-se aqui de repetição de indébito de natureza tributária (a afastar, portanto, a incidência da Lei Federal n. 9.497/97 e da Lei Federal n. 11.960/2009).

Com efeito, tratando-se de indébito tributário, de se aplicar, por questão de isonomia, os mesmos índices previstos para correção e remuneração do ativo fazendário, confira-se:

"Apelação cível. Autora portadora de insuficiência coronária. Isenção do imposto sobre a renda e imunidade parcial da contribuição previdenciária. Benefício concedido administrativamente e posteriormente revogado. Ausência de indicação de motivos que justifiquem a submissão da autora a nova perícia. Juros de mora. Aplicação dos mesmos índices previstos para mora no pagamento de tributos. Princípio da isonomia. Precedente desta C. Câmara - Recurso desprovido" - Apelação nº 1021401-54.2015.8.26.0053, 2ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargadora Luciana Bresciani, j. 28.06.2016.

"Apelação. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito. Taxa de limpeza pública - Inconstitucionalidade. Serviço público não específico e indivisível, que afronta o artigo 145, inciso II da CF e normas do CTN - É cabível a restituição do indébito correspondente à taxa, desde que não operada a prescrição - Atualização do débito que deve seguir os mesmos parâmetros utilizados pela administração para a correção do seu próprio crédito - Recurso desprovido" - Apelação / Reexame

Necessário nº 0002923-98.2014.8.26.0554, 14ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargadora Mônica Serrano, j. 25.02.2016.

Esse, aliás, o entendimento adotado pelo Col. Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4.357/DF, m. v., relator para o acórdão Ministro Luiz Fux, j. 14.03.2013, e respectiva questão de ordem (j. 25.03.2015).

A respeito:

"(...) 5. O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão 'independentemente de sua natureza', contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. (...)” - Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.357/DF, Pleno do Col. Supremo Tribunal Federal, m. v., relator para o acórdão Ministro Luiz Fux, j. 14.03.2013.

"QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. (...) 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. (...)” - Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.357/DF, Questão de Ordem, m. v., Pleno do Col. Supremo Tribunal Federal, relator Ministro Luiz Fux, j. 25.03.2015.

E é o entendimento que manteve o Pretório Excelso em sede de Repercussão Geral

(Tema 810), no Recurso Extraordinário n. 870947/SE (m. v., relator Ministro Luiz Fux, j. 20.09.2017), o que, portanto, deve ser seguido e observado pelas instâncias ordinárias.

Confira-se, conforme nota extraída do sítio eletrônico do Col Supremo Tribunal Federal:

"O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017", grifo nosso.

Por conseguinte, de se aplicar, ao caso, a taxa SELIC, por ser esse o encargo moratório previsto para os ativos fazendários, nos termos da Lei Estadual n. 10.175/1998, com o que, por questão de isonomia, também deve ser ele aplicado para os passivos fazendários.

Nesse sentido:

"A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices". (Súmula 523 do E. Superior Tribunal de Justiça).

Na mesma linha de entendimento:

"TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. JUROS DE MORA. DEFINIÇÃO DA TAXA APLICÁVEL. 1. Relativamente a tributos federais, a jurisprudência da 1ª Seção está assentada no seguinte entendimento: na restituição de tributos, seja por repetição em pecúnia, seja por compensação, (a) são devidos juros de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188/STJ, sendo que (b) os juros de 1% ao mês incidem sobre os valores reconhecidos em sentenças cujo trânsito em julgado ocorreu em data anterior a 1º.01.1996,

porque, a partir de então, passou a ser aplicável apenas a taxa SELIC, instituída pela Lei 9.250/95, desde cada recolhimento indevido (EResp 399.497, ERESP 225.300, ERESP 291.257, EResp 436.167, EResp 610.351). 2. Relativamente a tributos estaduais ou municipais, a matéria continua submetida ao princípio geral, adotado pelo STF e pelo STJ, segundo o qual, em face da lacuna do art. 167, § único do CTN, a taxa dos juros de mora na repetição de indébito deve, por analogia e isonomia, ser igual à que incide sobre os correspondentes débitos tributários estaduais ou municipais pagos com atraso; e a taxa de juros incidente sobre esses débitos deve ser de 1% ao mês, a não ser que o legislador, utilizando a reserva de competência prevista no § 1º do art. 161 do CTN, disponha de modo diverso. 3. Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do STJ considera incidente a taxa SELIC na repetição de indébito de tributos estaduais a partir da data de vigência da lei estadual que prevê a incidência de tal encargo sobre o pagamento atrasado de seus tributos. Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção. 4. No Estado de São Paulo, o art. 1º da Lei Estadual 10.175/98 prevê a aplicação da taxa SELIC sobre impostos estaduais pagos com atraso, o que impõe a adoção da mesma taxa na repetição do indébito. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08" - Recurso Especial n. 1111189/SP, 1ª Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministro Teori Albino Zavascki, j. 13.05.2009.

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. APLICABILIDADE. TEMA JÁ APRECIADO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (Resp 879.844/MG). LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. CABIMENTO. VERBA HONORÁRIA INDEPENDENTE DAQUELA FIXADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. É legítima a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros de mora sobre os débitos do contribuinte para com a Fazenda Estadual, desde que haja lei local autorizando sua incidência (Resp 879.844/MG, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25.11.2009 - recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ). In casu, o Estado de São Paulo, como relatado pelo próprio recurso especial (fls. 140), previu a utilização da taxa Selic em sua Lei Estadual nº 10.175/98, preenchendo o requisito exigido para a sua aplicação. (...)” - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 50.118/SP, 2ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. 13.12.2011.

“(...) IV. A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC, o Recurso Especial 1.111.175/SP (Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJe de 01/07/2009), decidiu que, na restituição de tributos federais, aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1º de janeiro de 1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. Assim, se os pagamentos foram efetuados após 1º de janeiro de 1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido. No entanto, havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá, como termo a quo, a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, 1º de janeiro de 1996. V. Especificamente na restituição de tributos estaduais ou municipais, a Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC, o Recurso Especial 1.111.189/SP (Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 25/05/2009), deixou consignado que, na restituição dos referidos tributos, a matéria relativa aos juros de mora continua submetida ao princípio geral, adotado pelo STF e pelo STJ, segundo o qual, em face da lacuna do art. 167, parágrafo único, do CTN, a taxa dos juros de mora, na repetição de indébito, deve, por analogia e isonomia, ser igual à que incide sobre os correspondentes débitos tributários estaduais ou municipais pagos com atraso, e que a taxa de juros, incidente sobre esses débitos, deve ser de 1% ao mês, a não ser que o legislador local, utilizando a reserva de competência, prevista no § 1º do art. 161 do CTN, disponha de modo diverso. VI. Em processo oriundo do Estado de Minas Gerais, a Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC, o Recurso Especial 879.844/MG (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/11/2009), considerou legítima a utilização da Taxa SELIC, na atualização dos débitos

tributários pagos com atraso, diante da existência de lei, no âmbito daquele Estado, que determina que os juros de mora serão calculados com base nos mesmos critérios adotados para cobrança dos débitos fiscais federais (art. 226 da Lei Estadual 6.763/75). VII. Após concluído o julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 - em que o STF declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/2009 -, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.270.439/PR (Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 02/08/2013), sob o rito do art. 543-C do CPC, deixou assentado que os juros moratórios serão os aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para a qual prevalecerão as regras específicas. VIII. Nos presentes autos, tendo em vista que se trata de Ação de Repetição de Indébito referente a contribuição previdenciária estadual, reconhecidamente de natureza tributária, não se aplica, ao caso, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, seja na redação dada pela Medida Provisória 2.180-35/2001, seja na redação da Lei 11.960/2009, devendo ser aplicada a taxa SELIC, nos termos da Lei Estadual (MG) 6.763/75, conforme estabelecido no acórdão do Tribunal de origem. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 406.310/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/02/2014; AgRg no REsp 1.427.058/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2014. IX. Agravo Regimental improvido" - Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1358785/MG, 2ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministra Assusete Magalhães, j. 16.10.2014.

E fica o registro, afastando-se qualquer confusão ou omissão, que é inaplicável, para fins de encargos da mora, a Lei Estadual n. 13.918/2009, ante a sua inconstitucionalidade, exatamente no ponto em que majorar a variação da taxa SELIC, confira-se:

"(...) o Órgão Especial, em decisão proferida em 2013, reconheceu em parte a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.918/09, devendo a taxa de juros ficar limitada à taxa SELIC. Referida Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, julgada em 27/02/2013, relatada pelo Des. Paulo Dimas Mascaretti, julgou 'procedente em parte a arguição, para o fim de conferir interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual nº 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual nº 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais'. (...) Assim, de rigor a exclusão do débito referente a parcela dos juros de mora que excede o limite da SELIC, nos termos em que decidido pela r. sentença. Nesse passo, não se cogita ainda que os juros de mora sejam calculados nos termos do art. 161, § 1º, do CTN, pois referido dispositivo legal impõe o cômputo dos juros de mora à taxa de 1% ao mês, 'se a lei não dispuser de modo diverso', o que não ocorre na espécie, em que o padrão da taxa SELIC foi adotado para a recomposição dos créditos tributários da União. (...) " - Apelação nº 1050719-19.2014.8.26.0053, 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, v. u., relator Desembargador Cláudio Augusto Pedrassi, j. 12.05.2015.

Tal encargo, correspondente à variação da taxa SELIC, porém, é e só pode ser aplicado como verba única, tanto para fins de atualização, como para fins de juros moratórios, concomitantemente, não podendo, pois, ser cumulado com qualquer outro, como acima, aliás, já consignado, nos termos da Súmula n. 523 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, tal encargo deve incidir desde cada desembolso (conforme entendimento firmado na Súmula n. 162 do E. Superior Tribunal de